

1512478-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... relação à imputação pelo delito de tráfico de drogas, devendo ser absolvido com relação ao delito de associação para o tráfico.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença - Processo nº 1512478-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512478-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142748/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 25189303 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2142748 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO EDUARDO DA CONCEIÇÃO e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CARLOS VINÍCIUS NERIS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com Paulo Eduardo da Conceição como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), em data incerta, mas antes de 25 de maio de 2022, nesta capital de São Paulo, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta ainda da denúncia que no dia 25 de maio de 2022, por volta das 12h30, na Avenida do Tanque, nº 10, Sapopemba, nesta capital de São Paulo, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si, guardavam e tinham em

depósito, para fins de tráfico, 33 porções de cocaína, com peso líquido de 31,7g, 44 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 5,9g, e 13 porções de maconha (tetraidrocanabinol), com peso líquido de 18,1g, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de fls. 13/16.

Relata a inicial que em local e horários incertos, anteriormente a 25 de maio de 2022, em São Paulo, os denunciados comungando dos mesmos propósitos, deliberaram-se associar-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Narra a exordial que, nesta quadra, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 12h30, na Avenida do Tanque, nº 10, Sapopemba, nesta capital, adquiriram, de qualquer forma, guardavam e tinham em depósito porções de cocaína, crack e de maconha, drogas diversas, com intenção de entregá-las a terceiras pessoas.

Expõe a denúncia que policiais civis realizavam campana no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram os denunciados realizando o comércio de drogas, motivando a abordagem.

Segundo a acusação, ao notarem a presença dos policiais, os denunciados tentaram empreender fuga, sendo detidos, logo após. Na ocasião, PAULO alegou que estava trabalhando como olheiro da biqueira, enquanto CARLOS admitiu o tráfico de drogas.

Aduz a inicial acusatória que no local, aos pés de CARLOS, no interior de uma bolsa, foram encontrados diversos entorpecentes, a saber, 33 porções de cocaína, 44 porções de crack e 13 porções de maconha, além do valor de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais), em notas trocadas.

Ao fim, é da exordial que as circunstâncias em que os denunciados foram abordados, em local conhecido pela prática do crime em tela, com relevante quantidade e diversidade de drogas, as quais estavam individualmente embaladas, aliadas à apreensão de dinheiro trocado, indicam que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.

Ao serem interrogados em solo policial, os acusados permaneceram em silêncio (fls. 19 e 20).

Em audiência de custódia, realizada aos 26 de maio de 2022 (fls. 60/61 e 75), a prisão em flagrante dos acusados foi homologada. Com relação ao acusado CARLOS, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao passo que para o acusado PAULO foi concedida a liberdade provisória, mediante a observância de algumas medidas cautelares alternativas (fls. 63/67).

Aos 08 de junho de 2022, foi concedida liberdade provisória ao acusado CARLOS. Na mesma oportunidade, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 04 de agosto de 2022 (fls. 91/93).

O acusado CARLOS foi citado pessoalmente em cartório (fl. 136). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de CARLOS, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 140).

Em 08 de julho de 2022, a denúncia foi recebida para o denunciado CARLOS (fl. 141).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis, tendo sido decretada a revelia do Réu Carlos.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente. Requereu a condenação do Réu Carlos somente com relação à imputação pelo delito de tráfico de drogas, devendo ser absolvido com relação ao delito de associação para o tráfico.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; c) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de

liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de parcial procedência.

A conduta imputada ao réu Carlos subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 05), Boletim de ocorrência (fls. 06/08), Auto de exibição e apreensão (fl. 11), Laudo de constatação (fls. 13/16), Relatório final de inquérito policial (fls. 83/84), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/149), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo Pericial de exame químico-toxicológico revelou resultado positivo para as substâncias cocaína (Itens 1 e 2) e tetrahydrocannabinol (Item 3).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Denis Alves da Silva, policial civil, relatou, em síntese, que é um ponto conhecido de traficância. Desceram e ficaram de campana do outro lado da avenida por aproximadamente 15 minutos. Carlos portava a bolsa e Paulo ficava de "olheiro". O depoente foi andando como usuário e quando chegou bem próximo do Carlos deu voz de prisão. Nesse momento, Paulo saiu correndo e o outro policial conseguiu a abordagem dele. Na bolsa tinham vários tipos de droga. Não conhecia os réus.

Também foi ouvida em juízo, a testemunha Raison Zappa Gil, policial civil, que narrou, em suma, que é um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Pararam um pouco longe com viatura descaracterizada. Por volta de 15 minutos de campana viram a traficância no local. O parceiro desceu como se fosse usuário e o depoente foi por trás. O depoente rendeu o réu Paulo. O Carlos tinha a bolsa, estava aos pés dele. Paulo era o "olheiro". Nessa bolsa estavam as drogas. Por volta de quatro vendas presenciaram em aproximadamente 15 minutos de campana. Informalmente eles confirmaram que estavam traficando. Nunca tinha visto os réus anteriormente. Paulo não tinha drogas. Paulo era o "olheiro", ficava um pouco mais distante, aparentemente perguntava o que a pessoa queria e encaminhava para Carlos.

Foi decretada a revelia do Réu Carlos.

Os depoimentos dos policiais civis foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como:

a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (55,7g no total) e forma de acondicionamento (em porções); c) pela apreensão de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais) em espécie, em diversas notas; d) pelo local e pelas circunstâncias da prisão. Todos estes fatores

são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu guardava e tinha em depósito as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Do crime de associação para o tráfico imputado aos réus - Artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Não restou suficientemente demonstrada com a segurança que se exige para a condenação que os réus integravam grupo estável e permanente criado com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes.

Consoante os magistérios de Guilherme de Souza Nucci¹:

"Associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os artigos 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa". (grifos nossos) Conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Para caracterizar o crime do art. 14, a associação deve ser estável." (STF - RTJ 170/291).

Vem a lume julgamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Para a configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja o animus associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio (...)." (STJ, HC nº 503.939/RJ (2019/0103768-2), Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data do julgamento: 10 de março de 2020).

No mesmo sentido:

"O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/76, não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade dirigida à prática do crime visado" (TJSP - RT 779/571).

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu CARLOS é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da certidão a fl. 127. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e

ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010.

Ementa: "(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços. Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)" (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para (1) ABSOLVER o acusado CARLOS VINÍCIUS NERIS DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (2) CONDENAR o acusado CARLOS VINÍCIUS NERIS DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade

de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido nas fls.

81/82 em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA